



# Urteil

## des Zivilgerichtspräsidiums Basel-Stadt

vom 20. Januar 2004

Aktenzeichen: V 2003 2290

Es wirken mit:

Präs. Dr. A. Heierli und Gerichtsschreiber lic. iur. M. Häuptli

---

In Sachen

**Documed AG**

Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel

vertreten durch Dr. Peter Mosimann, Advokat, Basel

**Gesuchstellerin**

gegen

**Davatz Zeno R. R.**

Winterthurerstrasse 52, 8006 Zürich

vertreten durch RA lic. iur. Stephan Stulz, Postfach 2441, 8022 Zürich

**Gesuchsgegner**

betreffend

**Urheberrecht/unlauteren Wettbewerb**

zieht das Zivilgerichtspräsidium des Kantons Basel-Stadt in Erwägung:

## TATSACHEN

### I.

Die Gesuchstellerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel. Seit 1979 gibt sie das „Arzneimittel-Kompendium der Schweiz“ heraus, dessen Inhalt sie seit 1998 auch über das Internet unter den Domains „documed.ch“ und „kompendium.ch“ verbreitet. Sie publiziert das Arzneimittel-Kompendium in Zusammenarbeit mit den Arzneimittelherstellern bzw. -importeuren, die damit einer gemäss Art. 13 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 der Arzneimittelzulassungsverordnung (AMZV, SR 812.212.22) bestehenden Pflicht nachkommen. Das Arzneimittel-Kompendium wird in Buchform unentgeltlich an die zur Abgabe von Medikamenten berechtigten Personen abgegeben. Es enthält einerseits Fachinformationen, d. h. Informationen über Arzneimittel, die sich an die Abgabeberechtigten richten, andererseits Patienteninformationen, die den Informationen auf den Beipackzetteln der Arzneimittel entsprechen. Die Fach- und Patienteninformationen können unentgeltlich über die von der Gesuchstellerin betriebene Website abgerufen werden.

Der Gesuchsgegner mit Wohnsitz in Zürich ist Inhaber der Einzelfirma „yweese“. Unter der Domain „oddb.org“ betreibt er eine Datenbank mit Arzneimittelinformationen. Über diese sind die im Arzneimittel-Kompendium enthaltenen Fach- und Patienteninformationen ebenfalls abrufbar.

### II.

Mit Eingabe vom 17. Dezember 2003 ersuchte die Gesuchstellerin um den Erlass einer superprovisorischen Verfügung mit den Rechtsbegehren:

- „1. Es sei dem Gesuchsgegner im Sinne einer vorsorglichen Massnahme superprovisorisch unter Strafandrohung zu untersagen, in Verletzung von Art. 10 URG und Art. 5 lit. c UWG die Daten und die Anordnung der Daten des Arzneimittel-Kompendiums der Schweiz ohne Zustimmung der Gesuchstellerin auf Datenträger zu übertragen, in irgendwelcher Form festzulegen und öffentlich entgeltlich oder unentgeltlich zu verbreiten, anzubieten oder sonstwie zu nutzen.
2. Es sei die vorsorgliche Massnahme mit Strafandrohung im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB (Haft oder Busse) zu verbinden.
3. Alles unter o/e Kostenfolge zu Lasten des Gesuchsgegners.“

Sie führte dazu an, der Gesuchsgegner habe im September 2003 unzählige Male auf die Website der Gesuchstellerin zugegriffen und systematisch die Daten des Arzneimittel-Kompendiums kopiert. Dieses stelle ein geschütztes Werk dar, an dem die Gesuchstellerin die Urheberrechte innehave; ausserdem handle der Gesuchsgegner unlauter, indem er das marktreife Arbeitsergebnis der Gesuchstellerin durch technische Reproduktionsverfahren übernehme und verwerte.

Mit Verfügung vom gleichen Tage entsprach das Zivilgerichtspräsidium dem Gesuch vorsorglich ohne Anhörung der Gegenseite vollumfänglich und setzte eine Einsprachefrist.

### III.

Mit Einsprache vom 23. Dezember 2003 ersucht der Gesuchsgegner um Aufhebung der superprovisorischen Verfügung, eventualiter um Verpflichtung der Gesuchstellerin zu einer angemessenen Sicherheitsleistung. Er macht im wesentlichen geltend, er sei einzig an den durch die Zulassungsbehörde Swissmedic approbierten Fach- und Patienteninformationen interessiert, an denen der Gesuchstellerin keine Urheberrechte zustünden. Der Gesuchsgegner betreibe seine Datenbank auf einem völlig anderen System als die Gesuchstellerin, und das Erscheinungsbild und die Datenstruktur seien völlig verschieden. Die Zugriffe im September/Okttober 2003 hätten lediglich dem Abgleich und der Überprüfung der Daten gedient. Es fehle auch an einer drohenden Verletzung und an der Dringlichkeit des Verbots.

### IV.

Mit Eingabe vom 16. Januar 2004 hält die Gesuchstellerin an ihren Begehren fest. Sie verweist auf die Leistung, die sie zur Redaktion der Fachinformationen erbringe. Unlauter sei ferner, dass der Gesuchsgegner die Daten Dritten entgeltlich anbiete.

### V.

Zur Einspracheverhandlung vom 20. Januar 2004 erschienen Jürg Morant, Verwaltungsrat der Gesuchstellerin, der Beklagte sowie die Rechtsvertreter beider Parteien.

## ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

### 1.

Die Zuständigkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen besteht wahlweise am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, oder am Ort des für die Hauptsache zuständigen Gerichts (Art. 33 GestG). Die Gesuchstellerin stützt ihr Begehren auf Erlass einer vorsorglichen Verfügung auf einen Unterlassungsanspruch aus Urheberrecht sowie aus unlauterem Wettbewerb. Urheber- und wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche fallen unter den Begriff der „Klagen aus unerlaubter Handlung“ gemäss Art. 25 GestG, wonach ein Gerichtsstand am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person besteht. Da die Gesuchstellerin ihren Sitz in Basel hat, ist die örtliche Zuständigkeit zu bejahen.

Gemäss Art. 64 Abs. 3 URG bezeichnen die Kantone eine einzige für die Beurteilung urheberrechtlicher Zivilansprüche zuständige Instanz; im Kanton Basel-Stadt ist dies das Zivilgericht (Ziff. III des Gesetzes betreffend Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und des Vollziehungsgesetzes zum Urheberrechtsgesetz sowie betreffend Vollziehung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb, vom 17. Mai 1945, SG 216.200). Die Zuständigkeit des mit Urheberrechtssachen befassten Gerichts erstreckt sich auch auf die damit in sachlichem Zusammenhang stehenden Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (Art. 12 Abs. 2 UWG). Für den Erlass und die Aufhebung vorsorglicher Verfügungen liegt die Kompetenz beim Einzelrichter in Zivilsachen bzw. beim Instruktionsrichter (§ 260 Abs. 1 ZPO). Die sachliche und funktionale Zuständigkeit des urteilenden Gerichts ist somit gegeben.

### 2.

a) Voraussetzung für den Erlass einer vorsorglichen Verfügung ist im Bereich des Urheberrechts eine drohende Verletzung und ein daraus folgender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, was lediglich glaubhaft zu machen ist (Art. 65 Abs. 1 URG). Die Gesuchstellerin macht geltend, dass ihr an dem „Arzneimittel-Kompendium“ das Urheberrecht zustehe. Als mögliche Urheberrechte kommen in diesem Fall in Frage:

- ein Urheberrecht an den einzelnen Fach- und Patienteninformationen;
- ein Urheberrecht an der Nachbearbeitung solcher Informationen (Art. 3 URG);

- ein Urheberrecht an der Auswahl oder Anordnung der Informationen (Sammelwerk, Art. 4 URG);
- ein Urheberrecht an den Registern, welche die Informationen erschliessen.

b) Generell ist zunächst festzustellen, dass die Gesuchstellerin als juristische Person nicht originär Urheberrechte erworben haben kann, weil diese zunächst der natürlichen Person zustehen, die ein Werk geschaffen hat (Art. 6 URG). Bezüglich der allfälligen von ihren Arbeitnehmern geschaffenen Werke darf allerdings davon ausgegangen werden, dass die in Erfüllung des Arbeitsvertrags entstandenen Urheberrechte auf sie übergegangen sind, soweit dies der Zweck des Arbeitsvertrags erheischt (Zweckübertragungstheorie; Barrelet/Egloff, Urheberrecht, N 20 zu Art. 16); hinzu kommt, dass es sich gegebenenfalls um anonyme Werke handelt, bei denen bis zum Nachweis der Person des Urhebers bzw. der Urheberin die gesetzliche Fiktion besteht, dass die Gesuchstellerin als Herausgeberin die Rechtsnachfolgerin sei (Art. 8 Abs. 2 URG; Barrelet/Egloff, N 6 zu Art. 8).

c) Die Gesuchstellerin behauptet nicht, dass die Fach- und Patienteninformationen vollständig von ihren Arbeitnehmern verfasst worden seien. Vielmehr werden sie von den Zulassungsinhabern (Arzneimittelherstellern bzw. -importeuren) bei der Swissmedic zur Genehmigung eingereicht und danach von der Gesuchstellerin publiziert, wobei diese sich auf den Standpunkt stellt, dass sie daran noch massgebliche Bearbeitungen i. S. v. Art. 3 URG vornehme. Einen Sonderfall stellen die sogenannten „Pseudo-Fachinformationen“ dar, welche die Gesuchstellerin auf Wunsch der Zulassungsinhaber erstellt. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Umgestaltung der Patienteninformation, die nach festen Regeln vorgenommen wird (Eingabe Gesuchstellerin vom 16.1.2004, Beilage 7, Dokument CLK 03). Die Gesuchstellerin ist der Ansicht, dass der grosse redaktionelle Aufwand, den sie mit zahlreichen hochqualifizierten Mitarbeitern leiste, den urheberrechtlichen Schutz der Bearbeitung begründe. Diese Meinung findet in Literatur und Praxis keine Stütze; der Fleiss oder Aufwand, mag er von noch so qualifizierten Personen erbracht werden, ist weder ein hinreichendes noch ein notwendiges Kriterium des Urheberrechts. In welchem Umfang die Texte von der Gesuchstellerin verfasst oder bearbeitet werden, kann jedoch im vorliegenden Fall offen bleiben, weil sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, dass das Ergebnis (die Fach- und Patienteninformationen) ohnehin nicht urheberrechtlich geschützt ist.

d) Urheberrechtlichen Schutz als Werke geniessen geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Geistige Schöpfungen, die zwar neu, aber dem Bekannten so nah sind, dass auch beliebige andere die gleiche Form schaffen könnten, haben keinen individuellen Charakter (Barrelet/Egloff, N 8 zu Art. 2; BGE



110 IV 105); in diesem Sinne wird auch von statistischer Einmaligkeit gesprochen (Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, 80; Troller, Immaterialgüterrecht I, 362 f.). Keinen Schutz geniessen Sprachwerke, die banale Zusammenstellungen von Alltagsredewendungen oder durch die Sachlogik vorgegeben sind (Barrelet/Egloff N 13 zu Art. 2). Als mögliche Beispiele werden standardisierte Geschäftsbriefe (BGE 88 IV 128), Allgemeine Geschäftsbedingungen (SMI 1988 115), Formularverträge, Gebrauchsanweisungen usw. genannt (Barrelet/Egloff a.a.O.). Andererseits ist kein besonderer ästhetischer oder künstlerischer Wert erforderlich, *wenn* eine individuelle Gestaltung, im Falle von Sprachwerken als „selbständiges sprachliches Gepräge“, vorhanden ist; auch die „kleine Münze“ ist urheberrechtlich geschützt (Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht <sup>3</sup>2000, N 36, 79).

Bei den Fach- und Patienteninformationen handelt es sich um wissenschaftliche Texte, die zum einzigen Zweck haben, Fachpersonen bzw. Patienten über die wesentlichen Eigenschaften eines Arzneimittels aufzuklären. Ihr Inhalt ist in Anh. 4 Ziff. 3 bzw. Anh. 5.1 Ziff. 3, Anh. 5.2 Ziff. 3 und Anh. 5.3 Ziff. 4 zur AMZV detailliert geregelt. Die genannten Bestimmungen regeln in Bezug auf die Fachinformation den Aufbau einschliesslich der Reihenfolge („1. Name des Präparates, 2. Zusammensetzung: a. Wirkstoffe, b. Hilfsstoffe, 3. Galenische Form...“), in Bezug auf die Patienteninformation darüber hinaus sogar die Formulierungen der Überschriften („Was ist ... und wann wird es angewendet?“) und einzelner Texte („Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig...“). Die Fachinformationen sind bewusst knapp gehalten und bestehen z. T. nur aus stichwortartigen Aufzählungen. Die Patienteninformationen enthalten im wesentlichen dieselben Informationen, sind aber stets als vollständige Sätze, häufig im Imperativ der 3. Person Plural, ausformuliert („Schlucken Sie die Kapseln unzerkaut während einer Mahlzeit“). Eine individuelle Gestaltung der Formulierungen ist nicht erkennbar. Es handelt sich um banale Alltagsformulierungen, die sich aus dem allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch, den besonderen Gepflogenheiten bei der Formulierung von Patienten- und Fachinformationen und dem durch wissenschaftliche Fakten und gesetzliche Bestimmungen vorgegebenen Aufbau und Inhalt ergeben.

Abgesehen vom fehlenden individuellen Charakter spricht ein weiterer Grund gegen den Urheberrechtsschutz für Patienten- und Fachinformationen. Sowohl die Fach- als auch die Patienteninformationen müssen von der Zulassungsbehörde Swissmedic genehmigt werden. Zu diesem Zweck sind sie auf Deutsch oder Französisch (AMZV Anh. 4, Ziff. 1.1) bzw. in einer Amtssprache (AMZV Anh. 5.1, Ziff. 1.1) einzureichen. Die Genehmigung erfolgt mit der Zulassung gemäss Art. 7 der Verordnung über die Arzneimittel (VAM, SR 812.212.21), sofern es sich nicht um nachträgliche Änderun-

gen (Art. 16 i. V. m. Art. 10 f. VAM) handelt. Der Zulassungsverfügung wird als Teil der Verfügung ein Dokument angefügt, das die wesentlichen materiellen und rechtlichen Einzelheiten der Zulassung umschreibt (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 VAM). Die Gesuchstellerin bestreitet zwar, dass die Arzneimittelinformationstexte Teil der Zulassungsverfügung seien. Der Gesuchsgegner hat jedoch belegt, dass dies zumindest bei einer Zulassung vom Dezember 2003 der Fall war („Die Zulassungsbescheinigung vom ## [geschwärzt] Dezember 2003 sowie die beiliegenden Arzneimittelinformationstexte bilden integrierenden Bestandteil dieser Verfügung“), und es darf unterstellt werden, dass Swissmedic diesbezüglich eine einheitliche Praxis verfolgt. Damit werden diese Texte Teil einer behördlichen Entscheidung und sind durch das Urheberrecht nicht geschützt (Art. 5 Abs. 1 lit. c URG), wobei sich die Schutzunfähigkeit auch auf die von Swissmedic nicht zu genehmigende (AMZV Anh. 4 Ziff. 1.1), aber amtlich geforderte (Art. 14 Abs. 2 VAM) Übersetzung der Fachinformation erstreckt (Art. 5 Abs. 2 URG). Die Schutzunfähigkeit betrifft auch im amtlichen Werk wiedergegebene Werke von Privaten im Umfang der Wiedergabe (Barrelet/Egloff, N 6 zu Art. 5). Dagegen argumentiert die Gesuchstellerin, dass die Bezugnahme auf ein geschütztes Werk beim Erlass einer Verfügung, beispielsweise bei der Erteilung einer Baubewilligung, nicht zum Entfallen des urheberrechtlichen Schutzes des referenzierten Werks führen könne. Sie erkennt damit, dass die Sachlage bei der Genehmigung von Arzneimitteln eine völlig andere ist, weil die Aufnahme der Informationstexte in die Zulassungsverfügung im Hinblick darauf erfolgt, dass diese exakt in der genehmigten Form an alle abgabeberechtigten Personen zu verbreiten ist (Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 AMZV). Vergleichbares lässt sich von einer Baubewilligung nicht sagen.

e) Die Gesuchstellerin macht weiter geltend, dass das Arzneimittel-Kompendium ein geschütztes Sammelwerk darstelle. Sammlung oder Sammelwerk ist jede Zusammenstellung von Werken oder anderen Beiträgen, die selbst wieder als individuelle geistige Schöpfung erscheint (Barrelet/Egloff, N 4 zu Art. 4); originell muss die Auswahl oder die Anordnung der einzelnen Elemente sein (Art. 4 Abs. 1 URG). Das Arzneimittel-Kompendium ist nicht eine „umfassende“ (Gesuch Ziff. 7), sondern eine vollständige Sammlung der Fach- und Patienteninformationen aller in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel, so dass von vornherein keine geschützte Auswahl vorliegen kann (Etienne Calame, Der rechtliche Schutz von Datenbanken, 218). In Buchform enthält es alle Arzneimittel in alphabetischer Abfolge der Präparatebezeichnungen, was nicht nur nicht originell ist, sondern auch gar keine geistige Schöpfung darstellt. Worin die „firmeneigene Systematik“ (Gesuch Ziff. 11) bestehen soll, ist nicht erkennbar. Online werden die Suchergebnisse einer Abfrage entweder alphabetisch oder nach der Trefferquote („Score“) dargestellt. Letztere ist das Ergebnis eines Re-

chenprozesses und ebenfalls keine geistige Schöpfung der Gesuchstellerin. Damit kann dahingestellt bleiben, ob der Gesuchsgegner überhaupt eine Anordnung der Gesuchstellerin übernommen hat; dabei ist daran zu erinnern, dass die Übernahme aller Elemente eines in einer *Anordnung* bestehenden Sammelwerks sachlogisch nicht mit der Übernahme der Anordnung verbunden sein muss.

f) Die Gesuchstellerin führt an, dass die intensive Bearbeitung der Informationen u. a. dem Erstellen der Register diene. In der Verhandlung hat sie jedoch ausdrücklich festgehalten, dass sie nicht behaupte, dass der Gesuchsgegner die Register kopiert habe; diese können auch gar nicht von ihrer Website heruntergeladen werden. Die Frage des – prima vista zweifelhaft erscheinenden – Urheberrechtsschutzes an den Wirkstoff-, Firmen- und therapeutischen Registern kann damit offenbleiben.

g) Schliesslich macht die Gesuchstellerin das Urheberrecht an den sog. Links (Hyperlinks), d. h. den in einer Internetseite enthaltenen Seitenverweisen, „als Computerprogrammen“ geltend. Mangels Substantiierung ist nicht recht verständlich, was sie damit meint; weder sind Hyperlinks Computerprogramme, da sie keine Verfahren zur Lösung einer bestimmten Aufgabe (Algorithmen; Barrelet/Egloff, N 24 zu Art. 2) sind, noch ist ersichtlich, inwiefern der Gesuchsgegner Links der Gesuchstellerin kopiert haben soll.

### 3.

a) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche können aufgrund der unterschiedlichen Schutzzwecke neben immaterialgüterrechtlichen geltend gemacht werden (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, N 90 zu Art. 1), doch ist bei der Auslegung des UWG darauf Rücksicht zu nehmen, dass bei Fehlen einzelner immaterialgüterrechtlicher Schutzvoraussetzungen grundsätzlich von einem lauterer Verhalten auszugehen ist, sofern nicht andere Elemente die Unlauterkeit begründen (BGE 116 II 471). Voraussetzung für den Erlass einer vorsorglichen Verfügung ist auch im Bereich des Lauterkeitsrechts die Glaubhaftmachung einer drohenden Verletzung und eines nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils (Art. 28c Abs. 1 ZGB i. V. m. Art. 14 UWG).

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der Gesuchsgegner ihr marktreifes Arbeitsergebnis ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernehme und verwerte (Art. 5 lit. c UWG). Sie führt dazu aus, der Gesuchsgegner kopiere „die Datenbank sowie die darin enthaltenen Patienteninformationen“; es sei nicht erheblich, ob sich die technische Struktur und das Erscheinungsbild unterschieden.

Unter „Datenbank“ kann entweder eine Sammlung von Daten (vgl. EU-Richtlinie 96/9/EG, E. 17) oder aber das konkrete technische System, in



dem diese gespeichert sind, verstanden werden. Die Gesuchstellerin hat nicht substantiiert, inwiefern der Gesuchsgegner ihr Datenbanksystem kopiert hätte, und es scheint dies auch gar nicht möglich, da dieses von ihrer Website nicht heruntergeladen werden kann. Die Befragung von Jürg Morant hat ferner ergeben, dass auch die Register des Kompendiums nicht von der Website heruntergeladen werden können. Die Frage, ob ein Verstoß gegen das UWG vorliegt, beschränkt sich daher auf das dem Gesuchsgegner vorgeworfene Kopieren der in der Datenbank enthaltenen Daten, d. h. der einzelnen Fach- und Patienteninformationen, in ihrer Gesamtheit.

b) Dass die Patienten- und Fachinformationen oder zumindest die Datenbank als deren Gesamtheit ein marktreifes Arbeitsergebnis darstellen, steht wohl ausser Frage, zumal die Geschäftsidee des Gesuchsgegners gerade darin besteht, ebendiese zu vermarkten. Fraglos stellt das Kopieren der Informationen mittels Download von der Seite der Gesuchstellerin und Einfügen in die eigene Datenbank eine Übernahme des Arbeitsergebnisses „als solches“ durch technische Reproduktionsverfahren dar. Der Gesuchsgegner behauptet zwar, dass er bis zum August 2003 die Daten über einen lizenzierten Zugang zu den „GALDAT“-Daten, welche die von ihm benötigten Patienten- und Fachinformationen ebenfalls enthielten, bezogen habe und nach der Kündigung dieses Zugangs nur zum Datenabgleich und zur Vervollständigung auf diejenigen der Gesuchstellerin zugegriffen habe. Wie es sich damit verhält, kann jedoch im Rahmen der Überprüfung der vorsorglichen Verfügung dahingestellt bleiben, zumal durch die Logfile-Einträge auf dem Internet-Server der Gesuchstellerin (Gesuchsbeilage 18) dokumentiert ist, dass der Gesuchsgegner systematisch eine grosse Menge von Dokumenten der Gesuchstellerin heruntergeladen hat und damit wenigstens glaubhaft scheint, dass er diese in seine Datenbank eingespielen hat.

c) Als entscheidendes Kriterium verbleibt damit die Frage, ob die Übernahme *ohne angemessenen eigenen Aufwand* erfolgt ist. Es handelt sich um eine Wertungsfrage, die nur im Einzelfall zu beantworten ist, und überdies stellt sich die Frage, woran die Angemessenheit zu messen ist (Baudenbacher, N 53 zu Art. 5). Nach der Botschaft ist einerseits der Aufwand der Konkurrenten, andererseits der effektive Aufwand des Übernehmers mit seinem hypothetischen Aufwand bei Nachvollzug der einzelnen Produktionsschritte zu vergleichen (BBJ 1983 II 1071), wobei unklar bleibt, wie die beiden Vergleiche zueinander in Beziehung zu setzen sind (Baudenbacher, a.a.O.). Jedenfalls fällt ein unnötiger Aufwand des Ansprechers („Erstbewerbers“) ausser Betracht (Baudenbacher, N 55 zu Art. 5). Entscheidend ist, welche Kosten des Erstbewerbers in die Angemessenheitsprüfung einzubeziehen sind (Baudenbacher, N 54 zu Art. 5).

Vereinzelt ist vertreten worden, dass nur die unmittelbaren Produktionskosten des Erstbewerbers zu berücksichtigen seien (SMI 1990 434,

„Eurotax I“). Nach anderer Auffassung sind auch die Kosten der Schaffung des nicht geschützten geistigen Werks einzubeziehen und nur allgemeine Forschungs- und Betriebskosten nicht berücksichtigungsfähig (Baudenbacher, N 54 zu Art. 5, mNw.). Ferner stellt sich die Frage, ob zu berücksichtigen ist, in welchem Umfang der Erstbewerber seine Kosten bereits amortisiert hat (Baudenbacher, N 75 zu Art. 5). Da das Kriterium des angemessenen eigenen Aufwands dazu dient, den durch technische Übernahme ungerechtfertigt (unlauter) erlangten Wettbewerbsvorteil von den Fällen erlaubten Nachschaffens abzugrenzen (Baudenbacher, N 51 zu Art. 5), ist auf den Zweckartikel (Art. 1 UWG) zurückzugreifen. Danach folgt das UWG dem Leitbild des „wirksamen Wettbewerbs“ (Baudenbacher, N 34 f zu Art. 1). Daraus ist abzuleiten, dass Art. 5 lit. c UWG, im Gegensatz zu den Immaterialgüterrechten, die dem Rechtsinhaber stets eine (beschränkte) monopolistische Stellung verschaffen, nicht in einer Weise ausgelegt werden darf, die den wirksamen Wettbewerb behindert.

d) Für die hier interessierende Fragestellung ist dies insofern relevant, als sich in Bezug auf die wettbewerbliche Situation von Datenbanken oder -sammlungen, die aus Fakteninformation oder anderen ungeschützten Elementen bestehen, im wesentlichen zwei Fallgruppen unterscheiden lassen. Datensammlungen der ersten Gruppe bestehen aus Informationen, die von jedermann oder doch einem weiten Personenkreis erhoben werden können; dazu gehören z. B. Daten der Marktforschung und -beobachtung. In diesen Fällen ist es aus Sicht des wirksamen Wettbewerbs unerwünscht, dass ein neu auftretender Marktteilnehmer die vom Konkurrenten erhobenen Daten übernehmen dürfte, ohne dass der Aufwand des Erstbewerbers zur Datenerhebung berücksichtigt würde; denn dadurch würde der wirtschaftliche Anreiz, eine Datenerhebung durchzuführen, genommen. Zur zweiten Gruppe gehören Datensammlungen, die bei der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit quasi als Nebenprodukt anfallen, dessen Verwertung die Haupttätigkeit nicht konkurrenziert. Aufgrund der Bindung an einen bestimmten Geschäftsbetrieb handelt es sich in der Regel zugleich um Daten, für die es nur eine einzige Quelle gibt („sole source data“). Beispiele dafür sind die Adressdaten der Kunden eines Telefonnetzbetreibers oder die Programmdaten von Fernseh- und Radioveranstaltern. Da bei der Gewinnung solcher Daten kein Wettbewerb möglich ist, kann der Wettbewerb nur in der (Zweit-)Verwertung spielen, was aber voraussetzt, dass der Inhaber der Datenquelle diese entweder freiwillig zur Verfügung stellt oder aber dass sie sonstwie kopiert werden dürfen. Damit hier der wirksame Wettbewerb in der Verwertung der Daten nicht vereitelt und dem Inhaber der Datenquelle keine ungerechtfertigte Monopolstellung verschafft wird, scheint einzig eine Auslegung von Art. 5 lit. c UWG angemessen, die nur den Aufwand des Erstbewerbers zur *Aufbereitung* der bei ihm ohnehin vorhandenen Daten,

d. h. zur Umformung der betriebsinternen Datenbanken in ein marktfähiges Produkt, berücksichtigt.

Auf den ersten Blick scheint es, dass der vorliegende Fall der ersten Fallgruppe zuzuordnen sei, weil die Gesuchstellerin Daten verarbeitet und verwertet, die sie von Dritten (den Zulassungsinhabern) erhält, und als Verlegerin eines Buchs auftritt. Das Geschäftsmodell der Gesuchstellerin weist jedoch eine Besonderheit auf, die es erheblich von einer gewöhnlichen Verlagstätigkeit unterscheidet: Ihre Einnahmen erzielt die Gesuchstellerin im wesentlichen nicht durch den Verkauf ihrer Produkte, sondern dadurch, dass sie im Auftrag der Zulassungsinhaber die unentgeltliche Publikation der Arzneimittelinformationen besorgt, zu der diese gemäss Art. 13 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 AMZV verpflichtet sind, und zusätzlich offenbar auch dadurch, dass sie in Einzelfällen die Digitalisierung von Papiervorlagen (Art. 17 AMZV) und gewisse redaktionelle Arbeiten wie die Erstellung von „Pseudo-Fachinformationen“ übernimmt, die an sich von den Zulassungsinhabern zu erbringen wären. Aufgrund der Tatsache, dass sie die einzige von der Zulassungsbehörde anerkannte Publikation verlegt, müssen ihr alle zum Aufbau einer Datenbank mit Arzneimittelinformationen erforderlichen Informationen von den Zulassungsinhabern zur Verfügung gestellt und die dabei entstehenden Kosten von diesen vergütet werden (was sie in eine ungleich komfortablere Wettbewerbsposition bringt, als wenn der Gesuchsgegner dieselben Daten bei den Zulassungsinhabern erheben müsste). Damit erfüllt sie eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Zulassungsinhaber, welche diese gegen Entgelt an sie delegieren. Sie könnte es ohne weiteres dabei bewenden lassen, die Kompendien an die Abgabeberechtigten abzugeben. Die zum Zweck der Publikationstätigkeit erzeugte Datenbank, die zusätzlich verwertet werden kann, indem die Daten beispielsweise Dritten für die Integration in deren Softwareprodukte zur Verfügung gestellt werden, erscheint daher als blosses Nebenprodukt, dessen Verwertung die Haupttätigkeit der Gesuchstellerin in keiner Weise konkurrenziert. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass der Umstand, dass die Online-Datenbank des Gesuchsgegners den Anforderungen der AMZV nicht genügen soll, *gegen* das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs spricht, weil die Tätigkeit des Gesuchsgegners folglich nicht geeignet ist, die Kunden der Gesuchstellerin (d. h. die Zulassungsinhaber) abzuwerben.

Dies alles führt dazu, dass der vorliegende Sachverhalt der zweiten Fallgruppe zuzuordnen ist und bei der Beurteilung der Angemessenheit des vom Gesuchsgegner erbrachten Aufwandes nur der Zusatzaufwand der Gesuchstellerin berücksichtigt wird, der für den Betrieb ihrer unter „docu-med.ch“ angebotenen Online-Datenbank erforderlich ist. Die Gesuchstellerin gibt selbst an, dass das Datenbanksystem, dem die auf ihrer Website angebotenen Daten entnommen werden, zugleich ihrer Buchproduktion dient. Ihr



unter Art. 5 lit. c anzurechnender eigener Aufwand besteht daher nicht in der bereits zu anderen Zwecken erfolgten und amortisierten Erfassung und Bearbeitung der Fach- und Patienteninformationen, sondern in der Anpassung des Datenbanksystems an die Anforderungen einer Online-Datenbank, in der Gestaltung der Website, der Abfragemasken usw. *Dieser* Aufwand war aber durch den Gesuchsgegner mit vergleichbarem, wenn nicht grösserem Aufwand zu erbringen und konnte durch die blossе Übernahme der Arzneimittelinformationen nicht eingespart werden. Eine Verletzung von Art. 5 lit. c UWG ist daher zu verneinen.

e) Aus den obigen Ausführungen zur Auslegung von Art. 5 lit. c UWG ergibt sich, dass das Verhalten des Gesuchsgegners nicht unlauter ist und damit auch nicht unter die Generalklausel von Art. 2 UWG fällt.

#### 4.

Nach dem Gesagten ist die vorsorgliche Verfügung vom 17. Dezember 2003 aufzuheben, weil es der Gestuchstellerin nicht gelungen ist, das Bestehen eines materiellen Unterlassungsanspruchs glaubhaft zu machen. Angemerkt sei zusätzlich, dass die Verfügung wohl auch aus einem weiteren Grund aufzuheben wäre: Aufgrund der Alleinstellung als Anbieterin der streitgegenständlichen Arzneimittelinformationen stellt die Gestuchstellerin mit einiger Wahrscheinlichkeit ein marktbeherrschendes Unternehmen i. S. v. Art. 4 Abs. 2 KG dar, so dass der Gesuchsgegner aufgrund von Art. 7 KG einen Anspruch auf Belieferung haben könnte. Sollte sich diese Frage in einem ordentlichen Prozess stellen, hätte das Gericht ein Gutachten der Wettbewerbskommission einzuholen (Art. 15 KG). Es ginge kaum an, im vorliegenden Massnahmeverfahren mangels Möglichkeit, die kartellrechtliche Frage zu behandeln, eine Wettbewerbsbehinderung ohne weiteres zu verneinen und einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit des Gesuchsgegners für die voraussichtlich längere Dauer des Prozesses zu untersagen. Dies würde gegen das Gebot der Verhältnismässigkeit vorsorglicher Massnahmen (David, SIWR I/2, <sup>2</sup>1998, 182) verstossen.

#### 5.

Die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten folgen dem Entscheid in der Sache. Eine bezifferte Parteientschädigung wird nach baselstädtischer Praxis nicht zugesprochen, da die Gestuchstellerin zur Rechnung des Vertreters der Gesuchsgegners nicht hat Stellung nehmen können.



Demgemäss wird

**erkannt:**

:/// Die vorsorgliche Verfügung des Zivilgerichtspräsidiums vom 17. Dezember 2003 wird aufgehoben.

Die Gesuchstellerin trägt die ordentlichen Kosten mit einer Gebühr von CHF 4'000.— zuzüglich Auslagen sowie die ausserordentlichen Kosten des Verfahren.

Schriftliche Urteilsbegründung versandt am 27. Jan. 2004

**ZIVILGERICHT BASEL-STADT**

Der Gerichtsschreiber:

HEI  
Hä  
hi

